

次のⅠからⅢまでの【見解】は、刑事訴訟法第326条の同意（以下「同意」という。）の性質に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- Ⅰ. 同意は、公判において供述者に対し反対尋問を行う権利を放棄することである。
- Ⅱ. 同意は、公判において証拠能力を付与する訴訟行為である。
- Ⅲ. 同意は、原供述時において供述者に対し反対尋問を行うことができなかったこと、あるいは原供述時において裁判所が供述者の供述態度を観察することができなかったことについて、責問権を放棄することである。

【記 述】

- ア. Ⅰの見解に対しては、検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について、被告人側がこれを同意した上で、その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することができないことになるという批判がある。
- イ. Ⅰの見解に対しては、搜索差押手続が違法であっても、同意をすれば、同手続の搜索差押調書は証拠能力を有することになるという批判がある。
- ウ. Ⅱの見解に対しては、伝聞法則を反対尋問権の保障の観点からしか理解しておらず、裁判所による供述態度の観察という直接主義の観点が欠落しているという批判がある。
- エ. Ⅱの見解に対しては、同意の性質が伝聞証拠が排除される趣旨と関連しなくなり、刑事訴訟法第326条が同法第320条第1項で排除される伝聞証拠について証拠能力を認める規定となっていることとそぐわないという批判がある。
- オ. Ⅲの見解に対しては、刑事訴訟法第326条第1項が被告人の供述調書についても規定していることを説明できないという批判がある。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

まず、見解Ⅰ～Ⅲについて説明する。

1. 見解Ⅰについて

見解Ⅰは、証拠とすることの同意の本質は反対尋問権の放棄にあるとする。伝聞証拠が許容されないのは反対尋問権の保障のためであるものの、反対尋問権は放棄できる権利であるから、証拠とすることの同意により反対尋問権を放棄したときは、伝聞証拠が証拠能力をもつに至る。しかし、この説からは、(i) 被告人は自分自身に対して反対尋問が出来ないから、自白調書について反対尋問権の放棄はあり得ず、326条が被告人の供述調書(322条)を掲げている趣旨を説明できない。また、(ii) 実務では、当事者が書面の証拠採用には同意したうえで、証明力を争うため原供述者の証人尋問を請求するということがあるところ、この見解からは容認できないと批判される。

2. 見解Ⅱについて

見解Ⅱは、証拠とすることの同意は、証拠に証拠能力を付与する訴訟行為であると解する。被告人の自白を録取した書面についても、同意により証拠能力が付与されるとするのが本条の文理にも合致するし、実務の慣行とも合致する。この見解からは、同意した供述調書の取り調べ後にその証明力の弾劾のため原供述者を証人として喚問することも何ら差し支えない。また、被告人の同意した搜索差押調書は、搜索差押手続が違法であるか否かにかかわらず証拠能力が認められることになる。

3. 見解Ⅲについて

見解Ⅲは、同意は、伝聞証拠の証拠能力の欠如に対する責問権の放棄、すなわち、当事者が異議の申し立て(309条)をしないことによって、訴訟行為の瑕疵が治癒されるものであるとし、いわば被告人にとって不利益な手続的瑕疵を追認する処分権の行使とみるものである。この見解においても、同意は当事者の手続処分権に基づく証拠能力の付与行為とみるべきであるとし、反対尋問権は放棄されていないので、同意後に証人尋問することも可能となる。

以上を踏まえて、各記述の当否を検討する。

ア 正しい

見解Ⅰは、同意を反対尋問権の放棄と解するため、この立場に対し上記(ii)の批判にあるように、検察官が請求した被告人以外の者の供述調書について、被告人側がこれを同意した上で、その証明力を争うために供述者の証人尋問を請求することが出来ないことになるという批判がある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

搜索差押手続が違法であっても、同意をすれば、同手続の搜索差押調書は証拠能力を有することになるという批判は、被告人の同意した搜索差押調書は、搜索差押手続が違法であるか否かにかかわらず証拠能力が認められるとする、見解Ⅱに対する批判である。したがって、本記述は、見解Ⅰに対する批判としている点で、誤っている。

ウ 誤っている

伝聞法則を反対尋問権の保障の観点からしか理解しておらず、直接主義の観点が欠落しているという批判は、証拠とすることの同意の本質は反対尋問権の放棄にあるとする見解Ⅰに対する批判である。したがって、本記述は、見解Ⅱに対する批判としている点で、誤っている。

エ 正しい

見解Ⅱは、同意の性質について、証拠に証拠能力を付与する訴訟行為であると解するため、この立場に対しては、320条1項によって伝聞証拠が排除される趣旨である反対尋問権の保障と関連しなくなり、326条が320条1項で排除される伝聞証拠について証拠能力を認める規定となっていることにそぐわないとの批判がある。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

326条1項が被告人の供述調書についても規定していることを説明できないという批判は、上記(i)にあるように、被告人は自分自身に対して反対尋問ができないから、被告人の供述調書については反対尋問権の放棄はあり得ないという点で、証拠とすることの同意の本質は反対尋問権の放棄にあるとする見解Ⅰに対する批判である。したがって、本記述は、見解Ⅲに対する批判としている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

